



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do 1.0702.16.075074-2/001 **Númeraço** 0750742-
Relator: Des.(a) Rubens Gabriel Soares
Relator do Acórdão: Des.(a) Rubens Gabriel Soares
Data do Julgamento: 24/11/2020
Data da Publicação: 30/11/2020

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E OBSTRUÇÃO DE JUSTIÇA - ABSOLVIÇÃO EM FACE DE AMBOS OS DELITOS - NECESSIDADE - AUTORIA NÃO DEMONSTRADA - PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO" - CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM COLABORAÇÕES PREMIADAS - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CORROBORAÇÃO ESPECÍFICOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, § 16, INC. III, DA LEI Nº 12.850/2013 - RECURSO MINISTERIAL - RECRUDESCIMENTO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL - INVIABILIDADE - MATÉRIAS PREJUDICADAS - ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 01. Ausentes provas seguras de que o acusado, dolosamente, praticou ou concorreu finalisticamente para a prática dos elementos típicos dos arts. 344 do Código Penal e 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, necessária se afigura sua absolvição, mormente em face do princípio do "in dubio pro reo". 02. Nos termos do art. 4º, § 16, inc. III, da Lei nº 12.850/2013, mostra-se inadmissível a prolação de sentença condenatória fundada apenas nas declarações de colaboradores premiados. 03. Colaborações premiadas não consubstanciam provas, senão meros meios de obtenção de prova, devendo ser especificamente corroboradas por outros elementos que evidenciem, extreme de dúvidas, os fatos descritos na denúncia. 04. Não se prestam à corroboração de delações premiadas elementos genéricos, dissociados dos relatos contidos na denúncia ou incapazes de comprovar a específica realização dolosa das condutas imputadas a cada um dos acusados. 05. Tendo a apelação defensiva sido provida para absolver o acusado em face de todas as imputações delitivas, resta prejudicado o recurso ministerial exclusivamente dirigido ao recrudesimento das reprimendas e do regime prisional.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0702.16.075074-2/001 - COMARCA DE UBERLÂNDIA - 1º APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 2º APELANTE: FABRICIO ALVES ROCHA - APELADO(A)(S): FABRICIO ALVES ROCHA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

DES. RUBENS GABRIEL SOARES

RELATOR.

DES. RUBENS GABRIEL SOARES (RELATOR)

VOTO

FABRICIO ALVES ROCHA e CARLOS BARBOSA FRANÇA, devidamente qualificados e representados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais como incursos nas sanções do art. 344, na forma do art. 29, caput, ambos do Código Penal, e do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, porque, segundo consta da exordial acusatória:

"(...) COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. Consta das inclusas peças de informação que no dia 07 de dezembro

de 2016, durante a tarde, no interior da Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares, situada na cidade e comarca de Patrocínio/MG, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, concorreram, de qualquer forma, para que Rubens Santos Rodrigues usasse de grave ameaça em face de Eduardo Lucas dos Reis, réu nos autos 0702.16.046713-1, 4ª Vara Criminal, oriundo da Operação Serendipe, com o fim de favorecer interesse de FABRICIO ALVES DA ROCHA. Consta ainda das inclusas peças de informação que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, concorreram, de qualquer forma, para que Rubens Santos Rodrigues embaraçasse de qualquer forma investigação de infração penal que envolve organização criminosa, em apuração nos autos 0702.16.046709-9, 2ª Vara Criminal. Segundo apurou-se, em meados de 2016, foi deflagrada a Operação Serendipe nesta cidade, ocasião em que foram presos vários policiais civis de Minas Gerais, entre eles o denunciado FABRICIO. FABRICIO figura como réu em quatro processos da Operação Serendipe: 0702.16.046709-9, 2ª Vara Criminal, que apura a infração penal de organização criminosa; 0702.16.046713-1, 4ª Vara Criminal, que apura os delitos de corrupção passiva e ativa; 0702.16.046707-3, 2ª Vara Criminal, que apura as infrações penais de corrupção passiva e falsidade ideológica; 0702.16.046701-6, 4ª Vara Criminal, que apura os crimes de falsidade ideológica, tráfico de drogas e fraude processual. O denunciado CARLOS é um dos advogados constituídos pelo denunciado FABRÍCIO para defende-lo nos processos acima citados. Eduardo Lucas dos Reis figura como corréu de FABRÍCIO no processo 0702.16.046713-1 da 4ª Vara Criminal e como testemunha nos autos 0702.16.046709-9 da 2ª Vara Criminal. FABRÍCIO e CARLOS, então, se ajustaram para ameaçar Eduardo Lucas dos Reis, com o objetivo de que ele, como corréu no processo que apura os crimes de corrupção ativa e passiva, e testemunha nos autos em que foi imputado o crime de organização criminosa, não prestasse quaisquer declarações que incriminasse o primeiro. Para colocar o criminoso plano em prática, CARLOS fez contato com o também advogado Rubens Santos Rodrigues, contratando este para a realização de uma diligência na cidade de Patrocínio/MG, local em que Eduardo Lucas dos Reis estava recolhido.

CARLOS e Rubens se dirigiram à Patrocínio no veículo do primeiro, e no trajeto, ficou acertado que o último iria falar com Eduardo Lucas dos Reis, e deveria questioná-lo se iria manter o acordado no sentido de não incriminar FABRÍCIO nas audiências dos dois processos citados, que seriam realizadas na semana do dia 12 de dezembro de 2016, pois caso contrário ele e sua família corriam sério risco de morte. Chegando ao local dos fatos, Rubens ingressou na Penitenciária e, em rápida conversa com Eduardo, lhe repassou o recado dos denunciados. A conduta de Rubens, para a qual concorreram os dois denunciados, caracterizou, em relação aos fatos apurados no processo nº 0702.16.046713-1, coação no curso do processo, e em relação ao feito nº 0702.16.046709-9, 2ª Vara Criminal, obstrução da justiça, eis que nessa ação penal é apurado o crime de organização criminosa. Ante todo o exposto, denunciemos à Vossa Excelência: CARLOS BARBOSA FRANÇA e FABRÍCIO ALVES DA ROCHA como incursos no artigo 344, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, e no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/13, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal; Requeremos ainda que, autuada esta, sejam os denunciados notificados nos termos do artigo 514 do Código de Processo Penal, e, recebida a denúncia, citados para defesa preliminar, prosseguindo-se o feito nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, até final sentença condenatória, aplicando-se, em relação aos policiais civis, o efeito da condenação previsto no artigo 92, inciso I, alíneas a e b do Código Penal. (...) (sic, f. 01D/04D).

Notificados, os réus apresentaram defesas prévias às f. 65/66 e 67/72.

A denúncia foi recebida em 17 de março de 2017, mediante decisão de f. 84/84v.

Citados, os acusados apresentaram respostas à acusação às f. 122/139 e 141/172.

Em decisão de f. 195/195v, o MM. Juiz a quo ordenou o desmembramento do processo em relação ao acusado CARLOS BARBOSA FRANÇA, prosseguindo o presente feito apenas em relação ao réu FABRÍCIO ALVES ROCHA.

Após instrução processual, com oitiva de testemunhas (f. 213/214 - Mídia Digital de f. 217), interrogatório do acusado (f. 215/215v - Mídia Digital de f. 217) e alegações finais das partes (f. 212 - Mídia Digital de f. 217), o MM. Juiz Sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado FABRÍCIO ALVES ROCHA pela prática dos delitos tipificados nos arts. 344 do Código Penal e 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal.

Ao acusado, foram impostas as penas de um (01) ano e dois (02) meses de reclusão, mais pagamento de dez (10) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, para o crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), e de quatro (04) anos e um (01) mês de reclusão, para o crime de obstrução de justiça (art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013), ficando as penas finais definitivas consolidadas em cinco (05) anos e três (03) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de dez (10) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A r. Sentença Penal Condenatória de f. 218/225v foi proferida em 19 de junho de 2017, tendo sido publicada no Diário do Judiciário Eletrônico em 06 de julho de 2017 (f. 258), com a intimação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em 21 de junho de



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

2017 (f. 231).

Embargos de Declaração interpostos pela Defesa de FABRÍCIO ALVES DA ROCHA às f. 232/237, tendo estes sido conhecidos e rejeitados mediante decisão de f. 282/283v.

Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS interpôs recurso de apelação à f. 231.

Em suas razões recursais (f. 295/306), pugnou pela reforma do julgado para que as penas-base sejam fixadas em patamares superiores aos adotados pela r. Sentença Penal Condenatória. Pleiteou, ainda, a incidência da agravante genérica do art. 61, inc. II, alínea "b", também quanto ao crime do art. 344 do Código Penal, além do recrudesimento do regime prisional para o fechado.

De outra parte, irresignada, a Defesa do acusado FABRÍCIO ALVES ROCHA interpôs apelação à f. 287.

Em suas razões recursais (f. 354/380), a Defesa do acusado RODRIGO pugnou, preliminarmente, pela absolvição do réu em face de ambos os delitos, com espeque no art. 386, incs. I ou II, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de investigação criminal e a conseguinte atipicidade das condutas. Suscitou, ainda, a incidência do princípio da consunção, haja vista a alegada identidade entre os tipos penais incriminadores dos arts. 344 do Código Penal e 2º, § 1º, da Lei



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

nº 12.850/2013. No mérito, pleiteou a reforma da r. Sentença Penal com o fito de absolvê-lo de todas as imputações, ante a ausência de provas suficientes de materialidade e autoria delitivas. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da reprimenda, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões defensivas apresentadas às f. 309/331 e contrarrazões ministeriais acostadas às f. 401/405.

Instada a se manifestar, a DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo conhecimento dos recursos, pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento parcial do recurso ministerial (f. 406/415).

É o relatório.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

1. Das preliminares.

Compulsando as razões do apelo defensivo, observo que as matérias arguidas como supostas preliminares consubstanciam, na verdade, questões meritórias, comportando apreciação, portanto, na seção apropriada do presente voto.

Com efeito, a alegada atipicidade das condutas em razão de suposta inexistência de investigação criminal e a aplicação do princípio da consunção, em razão de afirmada ocorrência de bis in idem, ante pretensa identidade de tipos penais incriminadores, são todas matérias de mérito, e não preliminares, como equivocadamente

as nomeia a peça recursal defensiva.

Deixo para apreciá-las, portanto, no tópico seguinte deste voto.

Assim, à míngua de preliminares ou nulidades arguidas pelas partes ou que devam ser declaradas de ofício, passo ao exame do mérito.

2. Do mérito.

2.1 Da apelação defensiva.

Pretende a Defesa do acusado FABRÍCIO ALVES ROCHA a reforma da r. Sentença de Primeiro Grau, com o fito de absolvê-lo das imputações delitivas referentes aos arts. 344 do Código Penal e 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, ao argumento de que não foram suficientemente comprovadas as condutas dolosas realizadoras de seus elementos típicos.

Sustenta, ainda, que a inexistência de investigação criminal e a absolvição do acusado em face do delito de organização criminosa, encartada nos Autos nº 0702.16.046709-9, conduziriam à inexorável atipicidade de sua conduta em face do tipo penal incriminador contido no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, o que determinaria sua absolvição nos termos do art. 386, incisos I ou II, do Código de Processo Penal.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Aduz, outrossim, que os arts. 344 do Código Penal e 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 possuiriam o mesmo tipo penal incriminador, de modo que a condenação pelos dois delitos consistiria em bis in idem.

Razão parcial assiste à Defesa. Senão vejamos.

Em primeiro lugar, cumpre assentar que, ao contrário do afirmado pela Defesa, preexistem diversos procedimentos investigativos sobre organizações criminosas supostamente integradas pelo acusado, podendo-se citar, a título exemplificativo, aquele que redundou na Ação Penal nº 0702.16.046709-9.

Ademais, a configuração do delito tipificado no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 não pressupõe, necessariamente, a existência de investigação policial, admitindo-se, em tese, a ocorrência de obstrução de justiça, por exemplo, em face de procedimentos investigatórios criminais conduzidos pelo Ministério Público, como ensinam CLEBER MASSON e VINICIUS MARÇAL:

"Desde logo, calha sublinhar que o crime em exame não se perfaz apenas quando o sujeito ativo impede ou, de qualquer forma, embaraça o andamento de inquérito policial de infração penal que envolva organização criminosa e, tampouco, se circunscreve à primeira fase da persecução penal. Tendo o legislador feito uso do termo investigação, inclui-se aí não apenas o inquérito policial, mas também qualquer outro procedimento investigatório criminal - como os PICs instaurados diretamente pelo Ministério Público com esteio na



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Constituição da República e na Resolução 13/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público) -, desde que instaurados com o escopo de apurar 'infração penal que envolva organização criminosa'." (In: Crime Organizado. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018, p. 112).

Deveras, como pontifica GUILHERME DE SOUZA NUCCI, mesmo a conduta obstrutiva perpetrada com o fito de embaraçar o deslinde de processos penais em curso nos quais seja apurada a prática do delito de organização criminosa poderá se subsumir ao tipo penal incriminador inscrito no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013:

"Segundo cremos, impedir ou embaraçar processo judicial também se encaixa nesse tipo penal, valendo-se de interpretação extensiva. Afinal, se o menos é punido (perturbar mera investigação criminal), o mais (processo instaurado pelo mesmo motivo) também deve ser." (In: Organização Criminosa. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 25).

Além disso, é irrelevante o fato de o agente ter ou não sido absolvido em relação ao delito de organização criminosa. Isso porque, para a prática do crime de obstrução de justiça, não é necessário que o agente integre a organização criminosa cuja investigação intenta embaraçar, bastando que realize as elementares do § 1º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

A acessoriedade verificada entre os delitos de organização criminosa e de obstrução de justiça não se transpõe para o sujeito ativo deste segundo delito, que pode ou não a integrar, como lecionam CLEBER MASSON e VINICIUS MARÇAL:

"Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo desse delito, não sendo exigida nenhuma qualidade ou condição especial do agente (crime comum). Em razão de pressupor a prévia existência do crime de "organização criminosa", está-se diante de um crime acessório, que pode ser praticado por uma única pessoa (monossujeito ou de concurso eventual), desde que esta não tenha, de qualquer forma, concorrido para a constituição/funcionamento da organização criminosa." (In: Crime Organizado. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018, p. 116).

Logo, não prosperam as alegações defensivas sobre a inexistência de investigação, tampouco a objeção sobre o fato de o réu não ter sido condenado pelo crime de organização criminosa noutro feito.

Pelas razões expostas, tais fatos não são hábeis, per se, para afastar, em tese, a tipicidade da conduta ou demonstrar a inexistência do fato criminoso.

Tampouco há que ser acolhida a tese relativa ao bis in idem, conforme a qual as imputações de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e de obstrução de justiça (art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013) não poderiam, prima facie, coexistir, dada a alegada identidade de suas elementares.

Como se deduz da narrativa constante da exordial acusatória, as duas imputações referem-se a fatos distintos. O suposto cometimento do delito de coação no curso do processo (art.

344 do Código Penal) teria se verificado em relação aos Autos nº 0702.16.046713-1, nos quais não se apura a prática de crime de organização criminosa, ao passo que a alegada perpetração do crime de obstrução de justiça (art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013) teria ocorrido no tocante aos Autos nº 0702.16.046709-9, nos quais se cuida do delito de organização criminosa.

Incorreta, outrossim, a afirmada identidade de tipos penais incriminadores, haja vista que o inculpado no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 é mais específico do que o descrito no art. 344 do Código Penal, dado que a conduta obstrutiva, naquele, incide sobre investigação relativa especificamente aos crimes de organização criminosa.

Portanto, *prima facie*, estivessem provadas a materialidade e autoria delitivas no tocante ao réu FABRICIO ALVES ROCHA, em relação a ambos os crimes, nada obstaría que fosse o acusado submetido às sanções dos dois plexos delitivos, em concurso material.

Feitas essas considerações preambulares, cabe averiguar se há nos presentes autos provas de que FABRICIO ALVES ROCHA, dolosamente, concorreu para que se usasse de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral, e/ou para que se impedisse ou, de qualquer forma, embaraçasse a investigação de infração penal que envolvia organização criminosa.

A materialidade delitiva, conquanto dubitável, estriba-se

nos diálogos travados pelo aplicativo WhatsApp às f. 02/05 e no termo de declarações do colaborador premiado RUBENS SANTOS RIBEIRO, de f. 06/13, além das provas orais consistentes nas declarações deste colaborador premiado e da testemunha EDUARDO LUCAS DOS REIS, também colaborador premiado.

Quanto à autoria, não há, nos presentes autos, provas seguras para a prolação de um édito condenatório em desfavor de FABRICIO ALVES ROCHA.

Conforme se extrai da denúncia de f. 01D/04D, a narrativa acusatória radica-se no fato de que em 07 de dezembro de 2016, a mando de CARLOS BARBOSA FRANÇA, advogado do réu FABRICIO ALVES DA ROCHA, o causídico e colaborador premiado RUBENS SANTOS RODRIGUES se dirigiu à Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares, situada na Comarca de Patrocínio/MG, e, em entrevista com o colaborador premiado EDUARDO LUCAS DOS REIS, que se encontrava preso naquele estabelecimento prisional, dirigiu ameaças e intimidações a este detento, a fim de que não prestasse quaisquer declarações que pudessem incriminar o réu FABRICIO ALVES ROCHA nos Autos nº 0702.16.046713-1 e 0702.16.046709-9.

Ainda segundo a tese acusatória, o réu FABRICIO ALVES ROCHA seria responsável pelos delitos tipificados nos arts. 344 do Código Penal e 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 29 do Código Penal, pois alegadamente teria concorrido para que a ordem supostamente emitida por seu advogado CARLOS BARBOSA FRANÇA ao advogado e colaborador premiado RUBENS SANTOS RODRIGUES, no sentido de que intimidasse EDUARDO LUCAS DOS REIS, se concretizasse.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Pois bem.

Interrogado em juízo, o acusado FABRICIO ALVES ROCHA negou veementemente a práticas dos fatos narrados na denúncia. Asseverou que jamais ajustou com seu advogado CARLOS BARBOSA FRANÇA qualquer intimidação ao colaborador premiado EDUARDO LUCAS DOS REIS e que, se seu causídico ordenou ao delator RUBENS SANTOS RODRIGUES que o fizesse, foi sem o seu conhecimento e anuência. Confira-se:

"FABRICIO ALVES DA ROCHA: (...) Então, na verdade, na delação dele, hora nenhuma é citado o meu nome, certo, apenas do Carlos Barbosa França, que também não acredito que os fatos são verídicos pela conduta e pela pessoa que eu conheço do Carlos Barbosa. Quanto à pessoa do Eduardo Lucas dos Reis, já conhecia uma vez no Ceasa e ele também, hora nenhuma, fala meu nome no processo, fala que foi a mando meu. E sim a denúncia do Ministério Público fala que eu e o Carlos se ajustaram. Se ajustaram como? Como? Cadê? Então eu não acredito que tenha provas relevantes no processo em meu nome. Excelência, de maneira alguma, e sim do Ministério Público colocando que a gente agiu previamente ajustados. E não teve esse ajuste, eu não me encontrei com o França e, de maneira alguma, eu pediria a algum advogado meu para fazer qualquer fato, qualquer ato que seja na prática de ilicitude. Então, eu não pedi isso ao França, se ele fez, foi de cunho próprio e eu acredito que não tenha feito também. (...) JUIZ DE DIREITO: Não houve orientação nesse sentido? FABRÍCIO ALVES DA ROCHA: Nenhuma minha. Não conversei nenhum dia com ele e não pedi a nenhum dos meus advogados para fazer algo de ilicitude, a nenhum deles. (...)\" (sic, transcrições de f. 430v/431) (destaque nosso).



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Sob o crivo do contraditório, a testemunha RUBENS SANTOS RIBEIRO, colaborador premiado, asseverou não conhecer o réu FABRÍCIO ALVES DA ROCHA, nunca ter com ele se encontrado, e que a suposta ordem para intimidação de EDUARDO LUCAS DOS REIS partiu do advogado CARLOS BARBOSA FRANÇA. Atente-se:

"(...)JUIZ DE DIREITO: Quando o senhor foi entrevistar com o Eduardo Lucas, o senhor se apresentou ao presídio como o advogado dele e que o Eduardo teria sido chamado o senhor?

RUBENS SANTOS RIBEIRO: Sim, Excelência.

JUIZ DE DIREITO: E aí o senhor teve acesso. Na sala, onde os senhores conversaram, ficou algum policial dentro?

RUBENS SANTOS RIBEIRO: Não, Excelência.

JUIZ DE DIREITO: Só o senhor e ele?

RUBENS SANTOS RIBEIRO: Só eu e o Senhor Eduardo. (...)

JUIZ DE DIREITO: E foi explicado para o senhor se efetivamente esse depoimento, que o Dudu daria em juízo, referia-se a esse policial, alcunhado por Ganso?

RUBENS SANTOS RIBEIRO: Eu não conheço ele. O Doutor Carlos França me falou Ganso, Fabrício. (...)

DRA. ANDREIA MOREIRA CARDOSO: O senhor disse que não conhece o acusado Fabrício?

RUBENS SANTOS RIBEIRO: Não conheço, doutora.

DRA. ANDREIA MOREIRA CARDOSO: O senhor já foi contratado por ele



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

para fazer alguma diligência?

RUBENS SANTOS RIBEIRO: Nunca fui. (...)" (sic, transcrições de f. 427v/428). (destaque nosso).

Por outro giro, a testemunha EDUARDO LUCAS DOS REIS, colaborador premiado, asseverou ter sido procurado pelo advogado e colaborador premiado RUBENS SANTOS RODRIGUES quando estava preso em Patrocínio/MG e que, durante a entrevista, este lhe teria dito para mudar seus depoimentos no sentido de não incriminar o acusado FABRÍCIO, dirigindo, sub-repticiamente, ameaças a ele e à sua família. Note-se:

"(...) PROMOTOR DE JUSTIÇA: Esse Rubens foi lá falar o que com o senhor?

EDUARDO LUCAS DOS REIS: Chegou lá e falou que era pra eu mudar o depoimento, que eu sabia com quem que eu tava mexendo, que era devido ao Guim ter morrido, né. Porque eu e o Guim trabalhava na sociedade. Aí ele ainda falou que, se eu tava vendo o que já tava acontecendo, era pra mim mudar o depoimento.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: E falou especificamente a respeito da ligação telefônica?

EDUARDO LUCAS DOS REIS: Também.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Que era para você dizer que não era com o Fabrício que você estava falando?

EDUARDO LUCAS DOS REIS: Ele falou que era pra mim mudar todos os depoimentos, né.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

PROMOTOR DE JUSTIÇA: O senhor se sentiu ameaçado naquele momento?

EDUARDO LUCAS DOS REIS: Senti. (...)" (sic, f. 422v) (destaque nosso).

Registre-se, portanto, que o arcabouço probatório constante dos presentes autos cinge-se a delações premiadas, aos dois depoimentos prestados em juízo por colaboradores premiados, e a telas de conversas de WhatsApp apresentadas por um dos colaboradores, nas quais não se vislumbra nenhuma prova do fato criminoso, a não ser a circunstância de que o delator RUBENS se encontrou com o advogado CARLOS BARBOSA FRANÇA e foi por ele contratado para uma diligência em Patrocínio/MG (f. 02/05).

Na prova oral e circunstancial coligida aos autos, não há nenhuma evidência de que a suposta intimidação exercida pelo colaborador premiado RUBENS por ordem do advogado CARLOS BARBOSA FRANÇA teve a anuência, o conhecimento ou a concorrência do réu FABRÍCIO ALVES ROCHA.

Ora, do mero fato de que ele se beneficiaria das condutas coativas e obstrutivas perpetradas pelo colaborador premiado RUBENS SANTOS RODRIGUES não se pode derivar, como consectário lógico, sua responsabilidade criminal por tais fatos.

A questão se mostra com obviedade translúcida: a circunstância de alguém se beneficiar de uma conduta criminosa não o torna, automaticamente, responsável por essa conduta.

Há que se compreender adequadamente o art. 29, caput, do Código Penal. Mencionado preceito estampa, na esteira da doutrina e da jurisprudência majoritárias, a teoria objetivo-formal de autoria. Nesses termos, autor do fato criminoso é aquele que realiza os elementos do tipo penal e partícipe é o agente que concorre para sua prática.

Tal concorrência para a prática, no entanto, há que se dar, forçosamente, no âmbito da responsabilidade subjetiva, haja vista o primado desta na seara penal e a adoção da teoria finalista da ação pelo Código Penal.

Aludido traço dogmático assoma evidente na própria redação do art. 29, caput, do Código Penal, preceito que sedimenta que o partícipe responderá "na medida da sua culpabilidade".

Assim, seja a culpabilidade entendida como potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, seja compreendida como o tipo subjetivo, é imprescindível a demonstração de que o agente possuía consciência e vontade de concorrer para a prática da infração penal, precisamente pelo rechaço da responsabilidade penal objetiva.

Meras suposições, calcadas no fato de o agente ter, supostamente, se beneficiado da ação criminosa, ou na circunstância de ser cliente do emissor da ordem ilegal, não podem lastrear uma condenação criminal.

Mais do que isso, é necessário, nos casos dos delitos tipificados nos arts. 344 do Código Penal e 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, que não admitem forma culposa, que o agente tenha atuado com consciência e vontade de realizar seus elementos típicos ou concorrer para sua consecução.

Logo, para que um édito condenatório acerca dessas imputações fosse proferido em desfavor do increpado FABRICIO ALVES ROCHA, mandatório seria que a Acusação comprovasse, extreme de dúvidas, que, anteriormente à ocorrência dos supostos fatos criminosos, o réu tivesse conhecimento das coações e obstruções a serem perpetradas e que as tivesse ordenado, ou, ao menos, que com elas tivesse anuído, expressa ou tacitamente, o que não se verificou na espécie.

Pelo contrário, o colaborador premiado RUBENS SANTOS RODRIGUES disse que não conhecia o réu FABRICIO ALVES ROCHA e que seu único encontro antes da ocorrência dos supostos fatos foi com o advogado CARLOS BARBOSA FRANÇA.

Do mesmo modo, a testemunha EDUARDO LUCAS DOS REIS, também delator premiado, não asseverou ter recebido coação, ameaça ou atuação obstrutiva por parte do réu FABRÍCIO ALVES ROCHA, tampouco apresentou elementos em seus depoimentos dos quais se pudesse depreender a ordenação, ciência ou anuência desse acusado em relação aos fatos narrados na denúncia.

Com efeito, o caráter subjetivo da responsabilidade penal

e a necessidade de individualização, não apenas das penas, mas das condutas penalmente relevantes, decorrem dos princípios constitucionais penais da culpabilidade da intranscendência, cujos consectários são expostos por NILO BATISTA:

"Em primeiro lugar, pois, o princípio da culpabilidade impõe a subjetividade da responsabilidade penal. Não cabe, em direito penal, uma responsabilidade objetiva, derivada tão-só de uma associação causal entre a conduta e um resultado de lesão ou perigo para um bem jurídico. É indispensável a culpabilidade. No nível do processo penal, a exigência de provas quanto a esse aspecto conduz ao aforisma 'a culpabilidade não se presume', que, no terreno dos crimes culposos (negligentes), nos quais os riscos de uma consideração puramente causal entre a conduta e o resultado são maiores, figura como constante estribilho em decisões judiciais: 'a culpa não se presume'. A responsabilidade penal é sempre subjetiva. Não há, no direito penal, responsabilidade coletiva, subsidiária, solidária ou sucessiva". (In: Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2007, p. 104).

SANTIAGO MIR PUIG elucida, outrossim, os corolários do princípio da culpabilidade, ressaltando o importante primado do Direito Penal do Fato, parâmetro indissociável para o exercício do jus puniendi estatal no Estado Democrático de Direito, donde decorre que a responsabilização penal somente pode ocorrer à vista da imputação de fato concreto, observável e comprovável no mundo exterior por condutas individualizáveis do acusado:

"A) El principio de personalidad impide castigar a alguien por un hecho ajeno. Hoy nadie admite la responsabilidad colectiva que en otro tiempo llevaba a castigar a todos los miembros de una familia o pueblo por el hecho de uno de ellos. Sin embargo, en la actualidad se plantea la cuestión de si deben responder penalmente las personas

jurídicas y las empresas o, alternativamente, los gestores de las mismas por los hechos formalmente realizados por aquéllas. B) El principio de responsabilidad por el hecho, que exige un "Derecho penal del hecho", se opone a la posibilidad de castigar el carácter o el modo de ser. Enlaza este principio con el de legalidad, y su exigencia de "tipicidad" de los delitos: el "mandato de determinación" de la ley penal reclama una descripción diferenciada de cada conducta delictiva. Ello se negó por el "Derecho penal de autor" y la teoría de los "tipos de autor" que propusieron los penalistas nacionalsocialistas: en lugar de castigar el homicidio, el hurto, las falsedades, etc. (tipos de conductas), el Derecho penal debía castigar al "homicida", al "ladrón", al "falsificador", etc... (tipos de autor). Adviértase cómo se confirma la vinculación política de cada una de ambas opciones. C) El principio de dolo o culpa - tradicionalmente la expresión más clara del principio de culpabilidad - considera insuficiente la producción de un resultado lesivo o la realización objetiva de una conducta nociva para fundar la responsabilidad penal. En el Derecho primitivo (así, especialmente en el germánico) no regía este principio, sino el contrario de la "responsabilidad objetiva" o "responsabilidad por el resultado", según el cual bastaba la causación de una lesión para que fuese posible la responsabilidad penal, aunque el autor no hubiese querido dicha lesión ni la misma se debiera a imprudencia. La evolución del Derecho penal ha seguido una línea tendente a la espiritualización de la responsabilidad penal, que ya se inició en el Derecho romano (no en sus principios) y llega a nuestros días, tras el paréntesis germánico de la Edad Media. Hoy se admite generalmente que la pena del delito doloso (querido) debe ser mayor que la del delito imprudente (culposo), y que si ni siquiera concurre imprudencia, porque el sujeto actuó con el cuidado que le era exigible, no cabe imponer pena alguna. Sin embargo, los vestigios de la "responsabilidad objetiva" han llegado hasta el presente, y hasta la reforma de 1983 el CP español conocía "delitos cualificados por el resultado" que suponían una responsabilidad penal que no requería dolo ni imprudencia, así como algún punto de apoyo para otras manifestaciones del llamado "versari in re illicita" -que permitía atribuir penalmente las consecuencias fortuitas de un acto inicial ilícito-. Estos conceptos, así como una fundamentación más precisa de la exigencia de dolo o imprudencia,

serán objeto de atención más amplia en el seno de la teoría del delito (cfr. infra, Lecciones 10 y 11). D) El principio de imputación personal impide castigar con una pena al autor de un hecho antijurídico que no alcance unas determinadas condiciones psíquicas que permitan su acceso normal a la prohibición infringida. Es lo que sucede en el caso de los inimputables, ya sea por ser menores de edad penal, ya por causa de enfermedad mental, defecto de inteligencia o percepción, o trastorno mental transitorio. Este principio puede apoyarse por de pronto, en la necesidad de que el hecho punible "pertenezca" a su autor no sólo material y subjetivamente, sino también como producto de una "racionalidad normal" que permita verlo como obra de un ser suficientemente responsable. De otro modo, en términos de Hegel, la pena no honraría al hombre como ser racional. El principio de igualdad real de los ciudadanos confirma esta exigencia de imputación personal como presupuesto de la pena. Se opondría a la igualdad imponer una pena, prevista para el que puede ser motivado normalmente por la ley penal, a personas que no gozan de dicha capacidad de motivabilidad normal. Si la llamada de la norma no puede motivarles con la eficacia normalmente prevista a causa de una inferioridad personal o situacional, no es lícito castigarles como si no poseyeran esta inferioridad." (In: Derecho Penal: Parte General. 8. ed. Barcelona: Editorial Reppertor, p. 126-127).

Impende observar, ademais, que, na esteira da teoria finalista da ação, a conduta penalmente relevante encontra sua significação jurídica na teleologia nela impressa por seu agente, não se qualificando tipicamente pela mera manifestação extrínseca causal, tal qual preconizara a teoria causalista. Assim, há que se rememorar os ensinamentos de HANS WELZEL:

"La acción humana es el ejercicio de la actividad finalista. La acción es, por lo tanto, un acontecer "finalista" y no solamente "causal". La "finalidad" o actividad finalista de la acción se basa en que el hombre,

sobre la base de su conocimiento causal, puede prever, en determinada escala, las consecuencias posibles de una actividad con miras al futuro, proponerse objetivos de diversa índole, y dirigir su actividad según un plan tendiente a la obtención de esos objetivos. La finalidad es un actuar dirigido concientemente desde el objetivo, mientras que la pura causalidad no está dirigida desde el objetivo, sino que es la resultante de los componentes causales circunstancialmente concurrentes. Por eso, gráficamente hablando, la finalidad es "vidente"; la causalidad es "ciega". La dirección finalista del acontecer causal es una prestación por la cual el hombre estructura, conciente de su finalidad, las obras de su vida de relación civilizada. Pero, como tal, es indiferente al valor, es decir, puede ser empleada lo mismo para la concreción de objetivos socialmente positivos, como socialmente negativos. En este punto se intercala el derecho penal, prohibiendo la concreción finalista de objetivos socialmente negativos." (In: Derecho Penal: Parte General. Tradução de Carlos Fontán Balestra. Buenos Aires: Roque Depalma Editor, 1956, p. 41.).

Portanto, tendo em vista os ditames da responsabilidade penal subjetiva, do princípio da individualização e da intranscendência das penas e da teoria finalista da ação, não se pode imputar ao acusado a prática dos delitos tipificados nos arts. 344 do Código Penal e 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, pelo mero fato de que, supostamente, ele teria se beneficiado da ação obstrutiva e coativa de um terceiro que sequer conhecia.

Tampouco há que se cogitar da aplicação das teorias do domínio do fato ou da cegueira deliberada, uma vez que não é exigível do cliente o monitoramento ou a onisciência sobre as ações de seu advogado, tampouco há relação hierárquica ou organizacional entre cliente e advogado que permita inferir algum dos consectários dessas teorias, adstritas aos chefes de associações criminosas ou

organizações, o que não incide na espécie.

À conta do exposto, merece reforma integral a r. Sentença Penal Condenatória que, em menoscabo à dogmática penal, considerou como provas suficientes de autoria o mero fato de o réu ser cliente do advogado que supostamente teria ordenado a prática das condutas intimidatórias pelo colaborador premiado, assim como a circunstância hipotética de ser o beneficiário dessas ações, malgrado a inexistência de qualquer indício sobre sua consciência e vontade de anuir para a prática dos fatos narrados na exordial acusatória.

Deveras, o entendimento esposado na Sentença de f. 218/225 corporifica repreensível adoção da responsabilidade penal objetiva e perigoso regresso ao causalismo penal, ferindo de morte os princípios da individualização e intranscendência das penas e o primado da responsabilidade penal subjetiva, pedras de toque do Direito Penal no Estado Democrático de Direito.

De mais a mais, como se sabe, no processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para subsidiar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Havendo dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição, em atenção ao princípio *in dubio pro reo*. Nesse sentido:

"Para se obter a certeza da criminalidade, é necessário que a prova indiciária apresente valor decisivo, acima de qualquer dúvida, apontando, sem esforço, o acusado como responsável pelo crime que lhe é imputado. Indícios, suspeitas, ainda que veementes, não são suficientes para alicerçar um juízo condenatório. A prova indiciária somente é bastante à incriminação do acusado quando formadora de uma cadeia concordante de indícios graves e sérios, unidos por um

liame de causa e efeito, excludentes de qualquer hipótese favorável ao acusado. Para a condenação é mister que o conjunto probatório não sofra embate da dúvida." (TAMG - AP. nº 204.264-4 - Rel. Juiz Audebert Delage - Julg. 27/02/96 - RT 732/701).

Destarte, as provas carreadas aos autos não conferem a certeza necessária para firmar o decreto condenatório em relação aos delitos de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e de obstrução de justiça (art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013), porquanto não comprovados fatos concretos a evidenciarem que o acusado, dolosamente, tivesse ordenado ou anuído, tácita ou expressamente, porém com consciência e vontade, para a prática das supostas coações e atos obstrutivos.

O Professor PAULO RANGEL, ao comentar o princípio do favor rei, que vige no processo penal, enfatiza:

"(...) estando o juiz diante de prova para condenar, mas não sendo esta suficiente, fazendo restar a dúvida, surgem dois caminhos: condenar o acusado, correndo o risco de se cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade, um culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver o acusado, mesmo que correndo o risco de se colocar um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas do que um inocente na cadeia". (In: Direito Processual Penal. 11. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006, p.33).

CAMARGO ARANHA também traz os ensinamentos do grande criminalista HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, no sentido de que:

"Nenhuma pena pode ser aplicada sem a mais completa certeza dos fatos. A pena, disciplinar ou criminal, atinge a dignidade, a honra e a estima da pessoa, ferindo-a gravemente no plano moral, além de representar a perda de bens ou interesses materiais (In: Da Prova no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, p. 64)

Ora, não se olvida que o réu possa realmente ter praticado os delitos em questão, mas disso não há provas irrefutáveis nos autos, motivo pelo qual não há como condená-lo pela prática de crimes tão severamente apenados. A respeito do tema, nunca é demais repisar que:

"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo; por isso absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do acusado, e não se oprime o da sociedade. A pena que atingisse um inocente perturbaria a tranquilidade social, mais do que teria abalado o crime que se pretendesse punir; porquanto todos se sentiriam na possibilidade de serem, por sua vez, vítima de um erro judiciário. Lançai na consciência social a dúvida, por pequena que seja, da aberração da pena, e esta não será mais a segurança dos honestos, mas a grande perturbadora daquela tranquilidade para cujo restabelecimento foi constituída; não será mais a defensora do direito e sim a força insana que pode, por sua vez, esmagar o direito indêbil." (Malatesta - in "Lógica das Provas" - Ed. Saraiva - págs. 14/15).

A propósito, anotamos respeitáveis julgados deste



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

EGRÉGIO TRIBUNAL:

"Uma sentença condenatória não pode ser baseada única e exclusivamente em indícios. A prova nebulosa, contraditória e geradora de dúvida quanto à autoria do delito não tem o condão de autorizar a condenação do réu não confesso, vez que ela não conduz a um juízo de certeza. A autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade não é bastante para ensejar a condenação criminal, por exigir esta a certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'. Nesse sentido, JTACRESP 42/323. O Estado que reprime o delito é o mesmo que garante a liberdade. O Estado de Direito é incompatível com a fórmula totalitária. Nele prevalece o império do direito que assegura a aplicação da máxima in dubio pro reo" (TJMG -1.0000 00268370-4/000(1) - IOMG - 20/09/2002, Rel. Des. Tibagy Salles).

"APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - FRÁGIL CONJUNTO PROBATÓRIO - ÔNUS DA ACUSAÇÃO -ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 'Em delito constante do art. 14 da Lei nº 10.826/03, a incerteza quanto à propriedade da arma apreendida favorece o acusado, motivo pelo qual deve ser mantida a absolvição, aplicando-se o princípio 'in dubio pro reo'.'"(TJMG 1.183.06.105546-7/001- Rel. Eduardo Brum. Data de Publicação: 11.01.2008)

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA NEGADA - AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - É ilegítima a condenação criminal baseada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, mormente quando a confissão extrajudicial do acusado não encontra respaldo em nenhuma outra prova colhida nos autos. II - Ainda que haja indícios de autoria, não havendo provas robustas para sustentar a condenação, impõe-se a absolvição do acusado com base no princípio in dubio pro reo" (Apelação Criminal 1.0223.07.228328-4/001.

Relator Des. Adilson Lamounier. Publicação: 06/04/2009).

Ademais, é cediço que não cabe ao réu fazer prova da sua inocência, pelo contrário, compete à Acusação comprovar de forma concludente a existência do fato ensejador da aplicação de pena, bem como sua autoria, porque é precisamente a certeza evidenciada do delito que legitima a condenação.

Nessas circunstâncias, tendo em vista a insuficiência do arcabouço probatório produzido na instrução criminal, prudente trilhar a senda absolutória.

Não bastasse a manifesta ausência de provas de autoria relativamente ao acusado FABRÍCIO ALVES ROCHA, outro óbice se verifica para a sustentação do édito condenatório na espécie.

Por certo, como já salientado, os únicos e pretensos elementos de prova coligidos aos autos são as declarações de dois colaboradores premiados, além de telas de conversas de WhatsApp juntadas por um deles, que nada provam em relação aos fatos narrados na denúncia.

Nesse diapasão, há que se conferir o que dispõe o art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/2013:

Art. 4º (...) § 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador: I - medidas cautelares reais ou pessoais; II - recebimento de denúncia ou queixa-crime III - sentença condenatória.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

GUILHERME DE SOUZA NUCCI esclarece a relevância do citado preceito, que proíbe a prolação de sentenças condenatórias fulcradas apenas nas declarações de colaboradores premiados:

"Temos defendido, há muito, o valor relativo da delação, pois é possível o envolvimento de vários interesses escusos, inclusive vingança, abrangendo mentiras e falsidades. Diante disso, o art. 4º, § 16, da Lei prescreve: 'nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador'." (In: Organização Criminosa. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 67).

Sobreleva observar, ainda, o quanto consignado pela MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, em seu bem lançado voto proferido no julgamento da Ação Penal nº 746-MT pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

"Em primeiro lugar, destaco que, de acordo com o § 16 do artigo 4º da Lei nº 12.850/2013, 'nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador'. Mais do que isso, consoante jurisprudência desta Corte Especial firmada antes mesmo do advento da lei que regulamentou o instituto, as declarações do réu colaborador não são suficientes, se isoladamente consideradas, sequer para o reconhecimento da justa causa (cf., nesse sentido, QO na Apn 514/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, julg. 28.10.2010, Dje 07.12.2010). Assim sendo, é imprescindível que a narrativa do réu colaborador seja corroborada por outros elementos de prova para que tenha algum valor probatório. Essa confirmação externa do depoimento do réu colaborador não deve ser examinada globalmente, mas fato a fato, imputação a imputação, pessoa a pessoa. Assim, 'é perfeitamente possível que parte do conteúdo da delação (p. ex.: um determinado crime) encontre corroboração em outras provas, e



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

parte não seja confirmada. Também é possível que haja prova concordante quanto a um dos delatados, e em relação a outro não' (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 463)." (APn 746/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2016, DJe 15/02/2017)

Em idêntico sentido, o seguinte aresto, também do COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

"Quanto ao aspecto processual, a natureza jurídica da colaboração premiada é de delatio criminis, porquanto é mero recurso à formação da convicção da acusação e não elemento de prova, sendo insuficiente para subsidiar, por si só, a condenação de alguém." (AgRg no Inq 1.093/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 13/09/2017)

Na mesma toada, o MINISTRO FELIX FISCHER, relator do HC nº 341.790/PR, concernente à denominada "Operação Lava-Jato", sedimentou que as declarações de colaborador premiado não consubstanciam provas, mas meros meios de obtenção destas: "como cediço tanto na jurisprudência quanto na doutrina a colaboração premiada tem natureza jurídica de meio de obtenção de prova. Dessa forma, um acordo de colaboração não enseja, por si só, uma sentença condenatória, aquele precisa estar amparado por um conjunto probatório, conforme o art. 4º, § 16, da Lei n. 12.850/13".

Do mesmo modo, o MINISTRO CELSO DE MELLO, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no âmbito da Petição nº 5.700/DF,

consignou que o instituto da colaboração premiada não é meio de prova, configurando-se como instrumento de obtenção de dados e subsídios informativos. Confira-se:

"(...) 3. A colaboração premiada, que não é meio de prova, acha-se legalmente disciplinada como instrumento de obtenção de dados e subsídios informativos. Valor e restrição concernentes ao depoimento do agente colaborador. O "Caso Enzo Tortoza" na Itália: um clamoroso erro judiciário. Registro, inicialmente, que o instituto da colaboração premiada, especialmente nos termos em que disciplinado pela Lei no 12.850/2013 (arts. 4o a 7o), vem sendo reconhecido, por esta Suprema Corte, com apoio no magistério doutrinário (VALDOIR BERNARDI DE FARIAS, "Delação Premiada: constitucionalidade, aplicabilidade e valoração", p. 135/158, 153, "in" "Temas Contemporâneos de Direito", org. por José Carlos Kraemer Bortoloti e Luciane Drago Amaro, 2009, Méritos Editora, v.g.), como relevante instrumento de obtenção de prova, e não como meio de prova (HC 127.483/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno), refletindo, em seu tratamento normativo, o que se delineou, no plano das relações internacionais, na Convenção de Palermo (Artigo 26) e na Convenção de Mérida (Artigo 37), ambas subscritas pelo Brasil e formalmente já incorporadas ao sistema de direito positivo interno de nosso País em virtude da promulgação, respectivamente, do Decreto no 5.015/2004 e do Decreto no 5.687/2006. Embora sofrendo críticas por parte de eminentes autores (CEZAR ROBERTO BITENCOURT e PAULO CÉSAR BUSATO, "Comentários à Lei de Organização Criminosa", p. 115/117, item n. 1, 2014, Saraiva; ROMULO DE ANDRADE MOREIRA, "A Delação no Direito Brasileiro", v.g.), o fato é que a Lei no 12.850/2013 "(...) traz aspectos positivos ao garantir ao delatado maior possibilidade de questionar o depoimento do delator, ao buscar diminuir a possibilidade de erro judiciário vedando-se condenação com fundamento exclusivo em delação, ao procurar garantir a integridade física do colaborador e ao regulamentar o acordo de colaboração, o que antes inexistia", tal como assinalam ROBERTO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO JUNIOR e

FABIO M. DE ALMEIDA DELMANTO ("Leis Penais Especiais Comentadas", p. 1.003/1.051, 1.031, 2a ed., 2014, Saraiva - grifei), cuja licença, no entanto, ainda que reconhecendo a eficácia desse instituto "na apuração de gravíssimos crimes", não deixa de questionar-lhe os aspectos no plano ético. O aspecto que venho de ressaltar - impossibilidade de condenação penal com suporte unicamente em depoimento prestado pelo agente colaborador, tal como acentua a doutrina (EDUARDO ARAÚJO DA SILVA, "Organizações Criminosas: aspectos penais e processuais da Lei no 12.850/13", p. 71/74, item n. 3.6, 2014, Atlas, v.g.) - constitui importante limitação de ordem jurídica que, incidindo sobre os poderes do Estado, objetiva impedir que falsas imputações dirigidas a terceiros "sob pretexto de colaboração com a Justiça" possam provocar inaceitáveis erros judiciais, com injustas condenações de pessoas inocentes. [...] Na realidade, o regime de colaboração premiada, definido pela Lei no 12.850/2013, estabelece mecanismos destinados a obstar abusos que possam ser cometidos por intermédio da ilícita utilização desse instituto, tanto que, além da expressa vedação já referida ("lex. cit.", art. 4o, § 16), o diploma legislativo em questão também pune como crime, com pena de 1 a 4 anos de prisão e multa, a conduta de quem imputa "falsamente, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração penal a pessoa que sabe ser inocente" ou daquele que revela "informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas" (art. 19). Com tais providências, o legislador brasileiro procurou neutralizar, em favor de quem sofre a imputação emanada de agente colaborador, os mesmos efeitos perversos da denúncia caluniosa revelados, na experiência italiana, pelo "Caso Enzo Tortoza" (na década de 80), de que resultou clamoroso erro judicial, porque se tratava de pessoa inocente, injustamente delatada por membros de uma organização criminosa napolitana ("Nuova Camorra Organizzata") que, a pretexto de cooperarem com a Justiça (e de, assim, obterem os benefícios legais correspondentes), falsamente incriminaram Enzo Tortoza, então conhecido apresentador de programa de sucesso na RAI ("Portobello"). (...)" (Supremo Tribunal Federal, Informativo nº 800, DJe 01/10/2015)

Desse modo, para além de não se conceber condenação criminal lastreada apenas em colaborações premiadas, os elementos de corroboração destas, para que se prestem a tanto, devem demonstrar especificamente os fatos narrados na denúncia em relação a cada um dos réus, não se admitindo como tais documentos que nada atestem sobre a autoria delitiva perscrutada, segundo leciona GUSTAVO BADARÓ (In: Processo Penal. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 463).

Destarte, tendo em vista que os únicos elementos constantes dos autos são as declarações de colaboradores premiados e cópias de conversas de WhatsApp juntadas por um deles que nada provam em relação ao réu FABRÍCIO ALVES ROCHA, tenho que incide o óbice contido no art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/2013, haja vista cingir-se o cipoal probatório às palavras de colaboradores, o que não pode subsidiar um édito condenatório.

Assim, à míngua de provas de autoria relativamente ao acusado, as quais devem abranger forçosamente o elemento subjetivo do tipo penal, na esteira da teoria finalista da ação, não há outro caminho que não a reforma do julgado para absolver o réu em face de todas as imputações delitivas, uma vez que a Acusação não se desincumbiu a contento de seu onus probandi.

Consoante lição de MIRABETE:

"Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a

fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou benefícios penais." (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 11.^a ed., São Paulo, Atlas, 2003, p. 474-5).

No mesmo sentido, a doutrina de FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO:

"Cabe, pois, à parte acusadora provar a existência do fato e demonstrar sua autoria. Também lhe cabe demonstrar o elemento subjetivo que se traduz por dolo ou culpa. Se o réu goza da presunção de inocência, é evidente que a prova do crime, quer a parte objecti, quer a parte subjecti, deve ficar a cargo da acusação." (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, 8.^a ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 1986, vol. 3, p. 214).

Logo, diante das provas colhidas ao longo da instrução criminal, verifica-se que estas são frágeis e, como é cediço, conjecturas e probabilidades existentes em desfavor do acusado são insuficientes para sustentar a prolação de um édito condenatório.

É curial, neste passo, invocar o magistério de FRANCESCO CARRARA, consoante o qual, no processo criminal, máxime para condenar, "tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica, porque a condenação



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

exige certeza, não bastando a alta probabilidade, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio" (In: Prova Penal. São Paulo: Editora Aide, 1994, p. 152).

Ademais, no dizer de MALATESTA "(...) para legitimar a absolvição, não ocorre a certeza da inocência, bastando julgá-la possível, dentro da incerteza da culpabilidade" (MALATESTA, Nicola Framarino Dei. A Lógica das Provas em Matéria Criminal, 2.^a ed. Trad. Paolo Capitanio, Campinas: Bookseller, 2001, p. 48-49).

Forte nessas razões, mandatária a reforma do decisum recorrido, a fim de absolver o acusado FABRICIO ALVES ROCHA em face de todas as imputações delitivas, o que se faz com espeque no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Assinalo que a presente absolvição se funda no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, e não nos incisos I e II do mesmo preceito, haja vista que não foi provada a inexistência do fato, sendo certa, contudo, a ausência de provas suficientes para a condenação do réu FABRICIO ALVES ROCHA, pelas razões acima expostas, porquanto subsistem, concomitantemente, dúvidas razoáveis sobre a materialidade e a autoria delitivas.

Nesse passo, perfilho o entendimento de EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA:

"Enquanto as primeiras causas referiam-se à demonstração de

certeza, nas hipóteses aqui mencionadas a sentença reconhece exatamente o contrário: a incerteza quanto à comprovação de determinados fatos, ligados à autoria e à materialidade do delito, resultando a absolvição pela insuficiência da prova colhida. A causa do inciso VII é bastante curiosa, para dizer o mínimo. Não haver prova suficiente para a condenação quereria dizer outra coisa que não a insuficiência de prova quanto à existência do fato ou de sua autoria, já mencionadas nos outros incisos? Ou seria apenas uma via reservada ao julgador quando este não estivesse plenamente convencido pelo exame das provas efetivamente existentes em relação à autoria e à materialidade? Ficamos com esta última hipótese, que se revela mais adequada ao contexto das disposições do art. 386." (In: Curso de Processo Penal. 21. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2017, p. 301).

Assim, em face da insuficiência do conjunto probatório para a formação de um juízo de certeza sobre a autoria e a materialidade delitivas, impositiva a absolvição de FABRICIO ALVES ROCHA com base no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

2.2 Do recurso ministerial.

Ante a reforma do decisum para absolver o acusado FABRICIO ALVES ROCHA em face de todas as imputações delitivas, fica prejudicada a análise do recurso ministerial, haja vista sua adstrição às reprimendas aplicadas, motivo pelo qual há que ser negado provimento à irresignação do Órgão Acusador.

3. Dispositivo.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DEFENSIVA, para absolver o acusado FABRICIO ALVES ROCHA em face de todas as imputações delitivas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Ante a absolvição do acusado, e não havendo motivos que justifiquem a manutenção de sua segregação cautelar no presente feito, determino que se expeça ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, para que seja imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Custas na forma da Lei.

É como voto.

DES. FURTADO DE MENDONÇA (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. JAUBERT CARNEIRO JAQUES - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO"



Tribunal de Justiça de Minas Gerais